

刑法第65条に関する次のⅠないしⅢの各【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち、誤っているものはどれか。

【見 解】

- Ⅰ. 刑法第65条第1項は真正身分犯の成立及び科刑についての規定であり、同条第2項は不真正身分犯の成立及び科刑についての規定である。
- Ⅱ. 刑法第65条第1項は身分が違法性に関係する場合についての規定であり、同条第2項は身分が責任に関係する場合についての規定である。
- Ⅲ. 刑法第65条第1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり、同条第2項は不真正身分犯の科刑についての規定である。

【記 述】

1. Ⅰの見解に対しては、真正身分犯が身分を連带的に作用させ、不真正身分犯が身分を個別的に作用させることの実質的根拠が明らかでないとの批判がある。
2. Ⅱの見解に対しては、身分が違法性に関係する場合と身分が責任に関係する場合を区別することは困難であるとの批判がある。
3. Ⅲの見解は、刑法第65条第1項が「共犯とする」と規定し、同条第2項が「通常の刑を科する」と規定していることを根拠の一つとしている。
4. Ⅰの見解に立った場合、甲が愛人である乙を唆して、乙が介護していた乙の老母の生存に必要な保護をやめさせた事例では、甲には保護責任者遺棄罪の教唆犯が成立し、科刑は単純遺棄罪の刑となる。
5. Ⅲの見解に立ちつつ、常習賭博罪における常習性が身分に含まれると解した場合、賭博の非常習者である甲が賭博の常習者乙を唆して、乙に賭博をさせた事例では、甲には常習賭博罪の教唆犯が成立し、科刑は単純賭博罪の刑となる。

No170

共犯と身分に関する見解

正答率

H25-7

正解

4

91%

1 正しい

I の見解は、法文の文理どおりに、65 条 1 項は真正身分犯の連帯作用について、同条 2 項は不真正身分犯の個別的な作用について定めたものと解する見解である。この見解に対しては、同じ身分でありながら、真正身分犯であれば連带的に、不真正身分犯であれば個別的に作用すること、すなわち、その作用を異にすることについての理由を示すことができないとの批判がある。

2 正しい

II の見解は、65 条 1 項は行為の違法性に関する身分（違法身分）の連帯作用について、同条 2 項は行為の責任に関する身分（責任身分）の個別作用について規定したものであると解する見解である。この見解に対しては、違法身分と責任身分との区別が明確でないとの批判がある。例えば、「業務」は 65 条 2 項で取り扱う身分であることに争いはないが、違法性が重大であるために刑が加重されているとの見解も有力である。II の見解を批判する立場からは、少なくとも真正身分犯か不真正身分犯かの区別は比較的容易であるのに対して、違法身分か責任身分かの区別はかなり困難であるとされる。

3 正しい

III の見解は、65 条 1 項は、真正身分犯及び不真正身分犯を通じて、身分犯における共犯の成立について規定したものであり、同条 2 項は、特に不真正身分犯について刑の個別作用を定めたものと解する見解である。この見解は、65 条は、非身分者についても身分者の共犯が成立することを同条 1 項で「共犯とする」と表現し、同条 1 項で共犯とされたもののうち非身分者の科刑について同条 2 項で「通常の刑を科する」としたと考えるのである。

4 誤っている

I の見解によると、第三者甲が、老母との関係で保護責任者となる乙を唆して老母の生存に必要な保護をやめさせた場合、乙には保護責任者不保護罪（218 条後段）が成立するが、217 条は不保護を処罰していないため、この場合は、保護責任者という身分が真正身分犯だということになり、甲も重い保護責任者不保護罪の教唆犯となる。

5 正しい

常習賭博罪（186 条 1 項）における常習性が身分に含まれると解した場合、常習者という身分は単純賭博罪（185 条本文）の刑を加重する身分であるから、不真正身分犯ということになり、III の見解に立つと、甲には、65 条 1 項により常習賭博罪の教唆犯が成立する。他方、その科刑は、65 条 2 項により単純賭博罪の刑となる。